



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 136/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: חנה נתיב
ע"י ב"כ עוה"ד אברהם דב ורבנר
מרחוב מנחם בגין 16 רמת גן

נ ג ד

הנתבעים: 1. גיל רוגוז'ינסקי
2. אסף בונין
ע"י ב"כ עוה"ד ציפורה בליצר
מרחוב החשמונאים 9 רמת גן

פסק דין

תובענה זו עניינה בבית המשותף ברחוב הרצל 59א רמת גן הבנוי על חלקה 486 בגוש 6127 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.

לטענת התובעת בסמוך לאחר רכישת הדירה על ידי הנתבעים, כשנתיים ומחצה לפני הגשת התביעה, הם פלשו לשטח החצר המשותפת והוסיפו לשטח דירתם כ- 90 מ"ר ללא קבלת הסכמה של בעלי הדירות וללא קבלת היתר בניה תוך שהם גם מפצלים את דירתם ל- 4 דירות נפרדות וגובים דמי שכירות חודשיים בסך של 10,000 ₪. בנוסף הנתבעים בנו שתי מרפסות בצד הדרומי של החצר וסיפחו חלק של כ- 50 מ"ר מהחצר הדרומית תוך יצירת כניסה נוספת לדירתם המורחבת ישירות מהחצר. הנתבעים אטמו את הכניסה לדירתם מחדר המדרגות בניגוד לדין וללא הסכמה. הנתבעים מבקשים לעצמם זכויות קנייניות עודפות במסגרת מו"מ לביצוע פרויקט תמ"א 38/2.

לאור האמור עתרה התובעת למתן צו אשר יורה לנתבעים לסלק את ידם מהרכוש המשותף ובכלל האמור להרוס את כל אשר נבנה ללא הסכמתה והסכמת בעלי הדירות. כן נתבקש חיוב הנתבעים בתשלום הוצאות המשפט.

הנתבעים טוענים כי התובעת הינה היחידה מבין בעלי הדירות אשר מעלה את הטענות המפורטות בהליך זה וכל בעלי הדירות האחרים דחו פנייתה אליהם להצטרף להליך. הנתבעים רכשו את הדירה בשנת 2007, במצבה כפי שהיא, ולא הוסיפו דבר לדירתם ולא השתלטו על כל שטח. הבית נבנה בשני שלבים – תחילה דירת הנתבעים ואח"כ הוספו הדירות האחרות בבית. מעולם לא היתה כניסה לדירתם מחדר המדרגות ותמיד הכניסה לדירה היתה נפרדת מהחצר. לא נפתח על ידי הנתבעים כל פתח כניסה חדשה לדירה. לטובת הנתבעים זיקת הנאה או זכות שימוש בלתי הדירה בשביל הגישה ובחצר הצמודה לדירתם. מרפסות אינן מהוות חלק מהרכוש המשותף אלא חלק בלתי נפרד מהדירות. כל מטרת התביעה היא לסחוט את הנתבעים. התובעת היא זו אשר מונעת ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 136/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

דיון

בטרם נכנס לדיון לגופן של טענות נכון יהיה להעיר כי כל הקשור בטענות התובעת בדבר פיצול דירת הנתבעים ודמי השכירות אותם הם גובים אינם נושאים לדיון בהליך שבפני וממילא לא נתבקש כל סעד בגינם. נושאים אלו גם אינם מצויים כלל בגדר סמכות המפקח (מכח דיני עשיית עושר לכאורה כנטען בסעיף 15 לכתב התביעה). אין באלו, אף אם יוכחו, להשפיע בדבר על ההכרעה הקניינית הנדרשת בהליך דנן.

כך גם כל הקשור בטענות הצדדים בדבר ה"אשם" באי קידומו של פרוייקט על פי תמ"א 38 בבית. ככל שיש דבר מה בטענות מי מהצדדים הרי שהדרך לדיון באלו הינה בהתאם להוראות חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008, ולא במסגרת ההליך דנן.

עתה ניתן לדון בטענות העומדות בפני להכרעה בהליך זה.

הרחבת דירה

הבית דנן נרשם בפנקס הבתים המשותפים עוד בשנת 1959. משכך, מסמכי רישום הבית המשותף ובכללם צו הרישום והתשריט, מהווים את נקודת המוצא והיסוד לזכויותיהם הקנייניות של הצדדים בבית.

בחינת תשריט רישום הבית המשותף אל מול המצב הקיים בפועל בדירת הנתבעים מלמד על כי בוצעה הרחבה בדירת הנתבעים, כפי שזו מפורטת בסעיף 12 לחוות דעת השמאי גדי יהודה (להלן: "חוות הדעת") - מן התמונות שצורפו לחוות הדעת עולה כי קונטור דירת הנתבעים בחזית הדרומית מגיע עד לקו קונטור הדירות בקומות העליונות (ר' תמונות בסעיפים 8.ב. ו- 8.ה. לחוות הדעת). מאידך, על פי תשריט הבית המשותף קונטור דירת הנתבעים אמור להיות בנסיגה של כשני מטרים (במיקום שמעל מרפסות דירת הנתבעים בחזית הדרומית). האמור מקבל תימוכין גם במסמכים התכנוניים אשר צורפו כנספח ה' לתצהיר הנתבע - בתשריטים שצורפו רואים בבירור את קו קונטור הדירות העליונות אשר בולט מעבר לקו קונטור דירת הנתבעים (למעט מרפסות דירתם).

מתשריט רישום הבית המשותף וחוות הדעת עולה כי חלק מהרחבת דירת הנתבעים בוצעה על גבי שתי המרפסות בחזית הדרומית המשוורטות בתשריט כחלק מדירתם והחלק האחר הינו במגרעת שבין מרפסות אלו.

כך גם אמורים הדברים בנוגע להרחבה הנטענת בחזית המערבית - השוואת מסמכי רישום הבית המשותף עם תמונות המצב הקיים בפועל מלמדות על סגירת המרפסת הצמודה לדירת הנתבעים.

דא עקא, בכך שהוכח כי דירת הנתבעים הורחבה אין די כדי להקנות לתובעת את הסעד המבוקש על ידה בהקשר זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 136/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הכלל הקבוע בחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") הוא כי על מנת לעשות שימוש ייחודי ברכוש משותף יש צורך בקבלת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית משותף. כך קובע סעיף 62(א) לחוק כי "אין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות". כך גם קובע סעיף 12(ב) לתקנון המצוי כי החלטה המשנה את זכויותיו של בעל דירה לא תהיה לה תוקף כלפיו, אלא אם אותו בעל דירה הסכים לה. המשמעות של הסעיף האמור, גם היא, כי נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות כדי לשנות את הזכויות הקנייניות בבית.

סימן 11 לחוק המקרקעין (הידוע גם כ"תיקון 18") מהווה חריג חקיקתי לכלל זה.

סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין קובע כלהלן: "על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

על פי ההלכה ההסכמה של בעלי הדירות (כולם או 3/4 מהם או 60% מהם, בהתאם לנסיבות על פי החוק) לכל גריעה מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה מסוימת צריכה להיות מפורשת (רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב פ"ד נה(3) 385, 402 ולסקירת הפסיקה בנדון גם ע"א (מחוזי חי') 1677/05 כרמל נ' ינקוביצי (פורסם בנבו)). הסכמה כנ"ל יכולה להינתן גם בעל פה ובלבד שהיא מוכחת בראיות מספיקות (עא (מחוזי ת"א) 2360/07 אילן הורוביץ נ' גיא נחמני (פורסם בנבו), ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטר, פ"ד לא(1) 382, ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78 וכן ת"א (חי') 744/05 יואלס נ' אידלברג (פורסם בנבו)).

בנסיבות דנן הוכחה הסכמה של רוב בעלי דירות בבית כנדרש בהוראות הדין כאמור לשם הרחבת דירת הנתבעים. ויוער, עיקר ההרחבה (הן בצד הדרומי והן בצד המערבי) בוצעה על גבי מרפסות של דירת הנתבעים. ויודגש, כיום גם התובעת מאשרת את זכותם של הנתבעים במרפסות, בין בעדותה (עמוד 6 שורה 25) ובין בעדות השמאי יהודה מטעמה (עמוד 11 שורה 6). משכך, ההסכמה הנדרשת, בעיקרה, הינה לבנייה ולא להצמדת השטחים עצמם (למעט שטח המגרעת כאמור).

ראשית, הוכח בפני כי ההרחבות בוצעו לפני שנים רבות, עוד לפני רכישת הדירה על ידי הנתבעים (בשנת 2007) ואף לא במשך 15 השנים האחרונות. כך עולים הדברים מעדות הנתבע - "הדירה שנקנתה כמו שהיא. לא נגענו בכלום" (עמוד 13 שורות 5-6), מעדות הגב' גוזמן "אני גרה משנת 2006. ש.ת. שינויים חיצוניים לא בוצעו, בטח שלא" (עמוד 18 שורות 17-18) ומעדות הגב' עזריה (עמוד 19 שורות 22-26). בכך נסתרה מניה וביה טענת התובעת כי העבודות בוצעו במהלך השנתיים ומחצה שלפני הגשת התביעה.

יוצא, אם כן, כי מדובר בהרחבות שבוצעו לפני שנים רבות ולא הוכחה בפני קיומה של כל טענה, ובודאי שלא כל תביעה, של מי מבעלי הדירות האחרים בבית, במשך כל אותם שנים. למעשה, אף



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 136/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת לא העלתה כל טענה בגין בניה זו לאורך שנים רבות, על אף שהינה בעלת דירתה כבר משנת 1994 ומעורה במתרחש בבית, לטענתה עוד משנת 1961 (עמוד 7 שורות 2-3).

שנית, הוכחה בפני ידיעה והסכמה ברורה ובכתב של בעלי הדירות בבית בנוגע לשינויים שבוצעו בבית המשותף ככלל וביחס לדירת הנתבעים בפרט.

פרוטוקול אסיפת בעלי דירות מיום 06.11.13 נחתם על ידי רוב בעלי דירות בהתאם להוראות תיקון 18 - בעלי דירות רשומים של 9 מתוך 11 דירות בבית (ועוד בעל דירה נוסף שאינו רשום) ואשר לדירותיהם צמודים 496/586 חלקים מהרכוש המשותף. מפרוטוקול זה עולה ידיעה ברורה של הצדדים כי מסמכי רישום הבית המשותף אינם משקפים עוד את הבנוי בפועל, לא רק בדירת הנתבעים אלא בכל הדירות בבית. הוסכם במפורש כי "כל עוד מתקיים מו"מ בהסכמת מרבית הדיירים לקראת תמ"א 38 לסוגיה, לא תהייה תביעות או תובענות ביחס לשטח הדירות הקיים לרבות שימוש ברכוש משותף ככל וזה קיים" (סעיף 7 לפרוטוקול).

במאמר מוסגר אציין כי הפרוטוקול האמור מעקר מתוכן כל "חשש" של התובעת בגין "עשיית עושר" לכאורה של הנתבעים במסגרת פרויקט תמ"א 38 ככל שיצא לפועל בבית (ר' סעיפים 4-6 לפרוטוקול).

שלישית, השוואת תשריט הבית המשותף עם חוות הדעת מלמדת על כי לא רק דירת הנתבעים הורחבה בחזית הדרומית אלא גם הדירות שבקומות מעליה - על פי תשריט הבית המשותף ברום הגובה שבמגרעת בין המרפסות בדירת הנתבעים בחזית הדרומית אמורות היו להיות מרפסות של הדירות העליונות. דא עקא, מהתמונות שבחוות הדעת עולה כי מרפסות אלו נסגרו גם בקומות העליונות, קרי, באותו שטח מגרעת שנסגר על ידי הנתבעים בין מרפסות דירתם בחזית הדרומית. חיזוק לאמור מצוי גם בעדותו של השמאי יהודה בהקשר זה בדיוק - "לא התמקדתי בדירות אחרות. סביר להניח שהמרפסות נבנו ביחד עם כולם. אני לא יודע איך אפשר לבנות את זה. אחרת היו רואים את זה" (עמוד 11 שורות 18-19) וכפי שמעיד גם הנתבע - "אם המרפסות נסגרו זה כמו כל המרפסות האחרות בבית. ש.ת. מדובר בשטח של כ-130 מטר סגור מסביב כולל הכל, כולל מרפסות פתוחות" (עמוד 13 שורות 5-7).

גם מסמכי הרישוי (נספח ה' לתצהיר הנתבע) מלמדים על סגירת מרפסות כאמור - כך, למשל, נכתב במסמך המלצות "משרד מהנדס העיר" - "מבקשים אשור לסגירת חלק מהמרפסות האמורות בדירה קיימת בקומה ב'".

הוראת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין קובעת כי "בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של בעל דירה אחרת באותו בנין". לפיכך, משעה שהרחבת דירת הנתבעים הינה לקונטור סגירת המרפסות של דירות אחרות בבית הרי שממילא ניתן לראות בבעלי הדירות הפונות לחזית הדרומית כמי שהסכימו להרחבת דירת הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 136/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שעה שההרחבות לדירות בבית בוצעו במקביל כאמור, הרי שיש בכך להוות הגנה לנתבעים לאור הסתמכותם של הסכמת בעלי הדירות האחרים בבית ואף בתמורה (הרחבה מקבילה בדירות אחרות) כאמור.

רביעית, הוכח כי בהליך התכנוני נתקבלה הסכמה של בעלי הדירות לסגירת המרפסות בחזית המערבית – "ישנה הסכמת ועד הבית בשם הדיירים" (מסמך "המלצות משרד מהנדס העיר" בנספח ה' לתצהיר הנתבע).

חמישית, לא עלה בידי התובעת להביא בפני ולו בעל דירה אחד נוסף התומך בטענותיה, בין כתובע ובין כעד מטעמה. אף לא הוגשה על ידה כל בקשה לזימון עד כאמור וזאת למרות שכבר במועד קביעת התיק לשמיעת ראיות הבהרתי כי לשם ההכרעה בתובענה תידרש "שמיעתם של עדים בין בעלי הדירות האחרים בבית. מדובר בתובענה בעניין הרכוש המשותף וראוי כי ישמעו עמדות בעלי הדירות בהקשר זה" (עמוד 3 שורות 2-4).

ההלכה קובעת בהקשר זה כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606).

ניתן בנסיבות אלו להסיק כי בעלי הדירות האחרים בבית אינם תומכים בטענתה של התובעת בהליך זה, כפי שמעיד הנתבע – "לא היו שום סכסוכים עם בעלי דירות. גם היום יש רק סכסוך עם חנה נתיב. לא היה רלוונטי להסדיר. ש.ת אני לא רואה עם זה שום בעיה. זו לא הייתה סוגיה עד היום. כל בעלי הדירות רואים את זה עין בעין חוץ מהתובעת" (עמוד 14 שורות 19-22). בכלל האמור אי העדתם של בעלי הדירות בבית מחזקת גם את המסקנה בדבר הסכמתם להרחבה שבדירת הנתבעים כאמור בין מכוח פרוטוקול אסיפת בעלי הדירות מיום 06.11.13, בין מכוח הוראות החוק לאור ההרחבות דומות ובין מכוח שתיקתם של בעלי הדירות לאורך שנים, ולמעשה, גם כיום והסתמכות הנתבעים.

וידגש, דווקא הנתבעים הביאו לעדות בפני שתיים מבעלי הדירות בבית - גב' גוזמן וגב' עזריה, שאף הן אינן תומכות בטענות התובעת.

שישית, שעה שמדובר בעתירה שעניינה בהרחבת דירה ומשקבעה, כאמור, קיומה של הסכמת רוב בעלי דירות בבית לביצוע ההרחבה, הרי שממילא לא זכאית התובע לכל סעד בעניין זה שעה שעתירתה איננה עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 71ג לחוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 136/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ולפני סיום פרק זה יובהר כי, מעבר לכך שלא עלה בידי התובעת להוכיח העדר קיומו של היתר בניה להרחבת דירת הנתבעים (ובהקשר זה אין אף בחוות הדעת לסייע שעה שלא עלה בידי השמאי לאתר אפילו את כתבי האישום וההיתרים שהוגשו בנוגע לדירת הנתבעים (ר' עמוד 9 שורות 12-30)), הרי שממילא אין כל נפקות לשאלת קיומו או העדרו של היתר בניה לצורך ההכרעה הקניינית הנדרשת בהליך דנן. דיני התכנון ובניה הינם דינים נפרדים ושונים מדיני הקניין בשיקולים הנבחרים, במטרות, בהליכים ובערכאות. אין באלו להשליך על אלו באופן ישיר.

לאור כל האמור לעיל הרי שהוכחה בפני קיומה של הסכמה בהתאם להוראות חוק המקרקעין להרחבת דירת הנתבעים ולפיכך אין מקום להיעתר לבקשת התובעת בהקשר זה, על אף התנגדותה.

פתח כניסה לדירה

לא עלה בידי התובעת להוכיח כי הנתבעים ביצעו שינוי כלשהו בפתח הכניסה לדירת וממילא לא בוצעה על ידם כל פגיעה ברכוש המשותף בבית בהקשר זה.

ראשית, על פי מסמכי רישום הבית המשותף אין כל כניסה לדירת הנתבעים מחדר המדרגות בבית. על פי תשריט הבית המשותף הכניסה לדירת הנתבעים הינה מהחזית הדרומית (שתי כניסות צמודות) ופתח כניסה נוסף בחזית המערבית (לכיוון צפון). ויוזכר, הבית המשותף נרשם עוד ביום 30.07.1959!

לכך חשיבות מהותית כאשר מדובר בתובענה המתנהלת בפני מפקח על רישום מקרקעין (ר' רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו ואח' נ' דן ירדני ואח' פד"י לח (4) 487).

שנית, על פי המסמכים התכנוניים שהוצגו בפני מהשנים 1959 ואילך (נספח ה' לתצהיר הנתבע) אין כל כניסה לדירת הנתבעים מחדר המדרגות בבית. גם על פי מסמכים אלו הכניסות זהות לאלו המפורטות במסמכי רישום הבית המשותף.

קיומה של כניסה נפרדת לדירת הנתבעים מהחצר מקבלת תימוכין גם מכך שהמסמכים התכנוניים (נספח ה' לתצהיר הנתבע) מאששים את עדותו של הנתבע לפיה הבית נבנה בשלבים, תחילה דירת הנתבעים ולאחר מכן נוספו הדירות האחרות בבית (ר' סעיף 5 לתצהיר הנתבע).

שלישית, לא הובאה בפני כל ראיה אובייקטיבית לקיומה של כניסה מחדר המדרגות לדירת הנתבעים. כל שהוצג מטעם התובעת בהקשר זה הם עדותה וחוות דעת השמאי. דא עקא, עדויות אלו קרסו בחקירתם הנגדית.

התובעת סימנה בעדותה את מיקומה של דלת הכניסה לכאורה לדירת הנתבעים מחדר המדרגות (מוצג 1/נ). דא עקא, מעברו השני של הקיר בתוך דירת הנתבעים מצוי פרוזדור לאורכו של הבית ובכיוון מנוגד לפתח הדלת הנטענת. אין כל היגיון או סבירות בקיומה של דלת במקום זה. גם התובעת איננה מסוגלת לספק כל הסבר לחיפוי האחיד הישן הקיים בחדר המדרגות, כפי שזה ניכר בבירור בתמונה בסעיף 8.ג. לחוות הדעת (עמוד 7 שורות 13-17). עדותה של התובעת בהקשר זה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 136/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

היתה רוויה בסתירות. כך, מחד אישרה כי "זה חיפוי ישן. אני לא יודעת ממת. ש.ת.ב-94 כשקניתי את הדירה החיפוי היה קיים" (עמוד 7 שורות 19-20) ומאידך גם אישרה "ב-94 הפתח לדירה מחדר מדרגות היה קיים" (עמוד 7 שורה 22). ברי כי פתח כניסה לדירת הנתבעים במקום הנטען על ידי התובעת מחייב היה ביצוע עבודות משמעותיות בחיפוי ולפיכך, אם לא החליפו הנתבעים את כל חיפויי חדר המדרגות (ואין כל טענה כי כך הם עשו) הרי שחלקי עדותה כאמור אינם יכולים לדור בכפיפה אחת, ודאי כאשר טענתה היא כי סגירת הדלת בוצעה על ידי הנתבעים רק בשנים האחרונות.

בתביעתה ובתצהירה טוענת התובעת כי הנתבעים הם אלו אשר פתחו את פתח הכניסה לדירתם "מהחצר המשותפת שסופחה בצד הדרומי של הבניין" (סעיף 17 לתצהירה). דא עקא, בעדותה היא מאשרת קיומה של כניסה לדירה גם מהחצר עוד בשנת 1961 - "אני לדירה הזו נכנסתי משנת 61 והייתה כניסה בחצר וכניסה מחדר המדרגות" (עמוד 7 שורה 2). שוב, עדותה של התובעת עומדת בסתירה פנימית.

השמאי יהודה מציין בחוות דעתו כי "לא מצאנו כניסה לדירה בתת חלקה מס' 1 מכיוון חדר המדרגות. כניסה זו נסגרה ונאטמה". מעדותו עלה כי הוא לא ממש בדק את סוגיית איטומה של הדלת (עמוד 10 שורות 23-29) ובעיקר הסתמך על דבריה של התובעת מטעמה הוגשה חוות דעתו. בסופה של העדות הוא כבר מאשר "אני כבר לא זוכר ולא יכול להצביע על נקודה מסיימת שבה ראינו את הסגירה של הדלת בחדר המדרגות" (עמוד 12 שורות 9-10). ויוער, השמאי אפילו לא בדק את קיומם של "שרידים" לאותו פתח נטען מתוך דירת הנתבעים (עמוד 12 שורה 7).

זאת ועוד. מעדותה של התובעת עולה כי "סגרו את הדלת לפני כמה שנים. אני לא יודעת. בחמש השנים האחרונות מתישהו סגרו את הדלת. אני לא יודעת מתי. לא הייתי כשסגרו את הדלת. ראיתי את התוצאות" (עמוד 8 שורות 18-19). משכך, מדובר בבנייה חדשה שניתן בנקל היה להבחין בה, ודאי שעה שנדרש היה תיקון של חיפוי השיש הישן בכל חדר המדרגות. דא עקא, השמאי לא הבחין בעבודה זו, לא הוצגה כל ראיה אובייקטיבית בהקשר זה וגם המצב העובדתי של חדר המדרגות (על פי התמונות שצורפו) אינו מדגים זאת.

רביעית, עדויותיהן של הגב' גוזמן (סעיף 3 לתצהירה) ובעיקר הגב' עטיה (סעיף 2 לתצהירה) מאשרות גם הן כי, לכל הפחות ב-15 השנים האחרונות, לא היה כל פתח לדירת הנתבעים מחדר המדרגות. עדויות אובייקטיביות אלו סותרות, מניה וביה, את עדותה של התובעת כאמור.

חמישית, גם בהקשר זה, בניגוד לנתבעים, אשר תמכו את גרסתם העובדתית בעדות בעלי דירות בבית, לא הובא לעדות ולו בעל דירה אחד נוסף מטעם התובעת.

שימוש בחצר

לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת כזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 136/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתיבה.

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277).

אין מחלוקת כי שטח החצר הדרומית הינו רכוש משותף. כך עולים הדברים ממסמכי רישום הבית המשותף הקובעים את הזכויות הקנייניות של הצדדים. כך עולים הדברים גם מעדות הנתבע - "זה לא חצר שלי ברמה הקניינית" (עמוד 13 שורה 12) ומאסיפת בעלי הדירות, לרבות התחייבות הנתבעים באותה אסיפה (נספח ד' לתצהיר הנתבע).

המחלוקת בהקשר דנן הינה בנוגע לשימוש המבוצע בחצר על ידי הנתבעים ובהקשר זה לא עלה בידי התובעת לשכנע כי מדובר בשימוש בלתי סביר.

ראשית, משעה שהוכח כי קיימת כניסה לדירת הנתבעים מהחצר הדרומית עוד במקור (משנת 1959 על פי מסמכי רישום הבית המשותף או משנת 1961 על פי עדות התובעת), הרי שברור הוא כי שימוש בחצר זו כשביל גישה לדירתם הינו בגדר שימוש סביר על פי מבחני המקום והזמן, ואף למעלה מכך, בגדר שימוש הכרחי (שעה שהוכח כי לא היתה כניסה לדירתם מחדר המדרגות). הדברים בהקשר זה אמורים גם בנוגע לשבילים המרוצפים לצורך גישה לדלת הכניסה לדירת הנתבעים בחזית הדרומית ולהיקף הבית בחזית המערבית.

שנית, אף שקיימים גדר ושער בכניסה לחצר הדרומית הרי שהוכח בפני כי אלו לא הותקנו על ידי הנתבעים והיו קיימים עוד לפני רכישת הדירה על ידם. עוד הוכח כי עובר לבעלות הנתבעים בדירתם חצר זו גם היתה נעולה על ידי הבעלים הקודמים וללא שימוש כלל של בעלי הדירות האחרים בבית. כך עולים הדברים מעדות הנתבע - "מאז ומעולם אף אחד לא נכנס לחצר הזו. היא הייתה סגורה ונעולה. כשאנחנו רכשנו את הדירה פתחנו את החצר. אין לי בעיה שאנשים יכנסו. זה לא חצר שלי ברמה הקניינית אבל אני היחיד שמשתמש בה. הכניסה לדירה היא מהחצר. נכון שזה לא כתוב אבל אני היחיד שמשתמש. גם באסיפה מ-6.11.13 אנחנו מציינים את זה. החצר לא שלנו כל עוד ימשך תהליך 38. זה לא חצר לצורך חישוב הזכויות שלי בתמ"א" (עמוד 13 שורות 11-15). עדותו זו נתמכת גם בעדויות הגב' גוזמן - "אני זוכרת שלא היו שינויים. כמו שקניתי בשנת 2006 ראיתי את הכניסה והחצר סגור עם בד ירוק. היה שער ומנעול. היה מפריע לי שתליתי כביסה ונפל לי. לא יכולתי ללכת כי זה סגור. עכשיו מאז שקנו את הדירה זה פתוח" (עמוד 18 שורות 19-21) והגב' עטיה (עמוד 19 שורות 23-24 ושורות 27-28). יוצא, אם כן, כי כל עוד השער אינו נעול הרי שאין בקיומה של הגדר כדי למנוע הגישה לחלקי הרכוש המשותף. גם עדותו של השמאי יהודה מלמד על כי אין כל הפרעה בגישה לחצר (עמוד 10 שורות 2-6).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 136/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שלישית, נכון לעת הזו, למעשה, ישנה הסכמה של רוב מוחלט של בעלי הדירות בבית להותרת הגדר במקומה כפי שעולה מפרוטוקול האסיפה מיום 06.11.13 - "מוסכם על גיל רוגוז'ינסקי ואסף בונין, בעלי הדירה בקומת הקרקע, כי הגינה המתוחמת הינה רכוש משותף ואין להם ולא תהיה להם, זכות בלעדית מכל סוג שהוא, לרבות זיקות הנאה. האמור ברישא של הסעיף בכפוף לכך שיישמר המצב הקיים, לרבות הגדר, כל עוד מתנהל המו"מ כאמור בסעיף 7 לעיל" (סעיף 8 לנספח ד' לתצהיר הנתבע). למעשה גם התובעת מאשרת הסכמה זו (עמוד 8 שורות 4-2).

משכך, כל עוד לא התקבלה החלטה אחרת של רוב בעלי הדירות בנוגע לגדר האמורה, הרי שאין מקום להסרתה, ובלבד שהשער בה יישאר לא נעול, כפי שהוא במצבו כיום.

שוב, גם בהקשר זה, התובעת עומדת בודדה ויחידה בתביעתה ללא תמיכה של מי מבעלי הדירות האחרים בבית (וחרף הסכמתם המפורשת באסיפה מיום 06.11.13 ועדויות חלק מהם בהליך בפני כאמור).

רביעית, לא רק שלא הוכחה הגבלה על השימוש של בעלי הדירות האחרים בחצר כאמור, הרי שהוכח כי בפועל ישנו שימוש גם לאחרים בחצר – "תמונה 4 להודעה. רק הבלונים הקטנים שלנו. הבלונים הגדולים לא שייכים לדירה" (עמוד 14 שורה 29).

הדברים האמורים נכונים לגבי השימוש בחצר לצורך הגישה לדירת הנתבעים ובכלל האמור גם לגבי הגדר התוחמת (כל עוד לא התקבלה החלטה אחרת של בעלי הדירות בבית). אולם, בכל הקשור לשימוש בחלק הפנימי של שטח החצר המגודר בקני במבוק, הדין הוא עם התובעת.

מן התמונה שבסעיף 8.ה. לחוות הדעת עולה כי הנתבעים גידרו חלק משטח החצר הצמוד פיזית לדירתם ועושים בו שימוש לצורכי אחסנה וכיוצ"ב. בניגוד לשימוש בחצר לצורך גישה לדירתם הרי ששימוש זה הינו בגדר שימוש ייחודי, בבחינת סיפוח השטח לשימושם הבלעדי.

מדובר, למעשה, בשימוש בחלק מהחצר המשותפת כמרפסת פרטית לכל דבר ועניין לדירת הנתבעים. בהקשר זה ניכר בבירור כי אין כל גישה לשטח זה אלא דרך דירת הנתבעים ומיקומו בסמוך לפתח יציאה מדירת הנתבעים מגביל ומונע בפועל כל שימוש של אחרים בחלק זה של החצר. אומנם, לדירת הנתבעים היו בעבר מרפסות בחזית הדרומית. אולם, כאמור, מרפסות אלו נסגרו ואוחדו לתוך דירת הנתבעים ואין בידם זכות קנויה לקיומה של מרפסת לדירתם בחצר המשותפת.

בנוגע לשימוש כאמור גם אין התייחסות מפורשת של בעלי הדירות באסיפה מיום 06.11.13 בניגוד, למשל, להתייחסות לגדר כאמור לעיל.

טענות הנתבעים אשר מתבססות על זכות השימוש בגדר "זיקת הנאה" אינן רלבנטיות לשימוש האמור שעה שאין זכות מסוג זיקת הנאה מקנה זכות חזקה (ר' סעיף 5 לחוק המקרקעין).

הנתבעים גם לא עמדו בנטל להוכיח כי בידם רשות שימוש בלתי הדירה כנטען.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 136/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ראשית, אף אם ניתנה ביד הנתבעים רשות שימוש הרי שזו נובעת משתיקת בעלי הדירות בהעדר הסכמה מפורשת בכתב לסיפוח החצר - "הסכמה בכתב לא הייתה. החצר הייתה נעולה עד לרגע שאנחנו רכשנו אותה. ש.ת אם אתה מדבר על הסכמה בכתב אין הסכמה" (עמוד 12 שורה 30 עד עמוד 13 שורה 1). רשות שימוש כאמור לקודמיהם בזכויות, אף אם ניתנה, הרי שלא הומחתה לנתבעים - "בחוזה מכר זה לא כתוב השימוש בחצר וזיקת ההנאה" (עמוד 13 שורה 3).

שנית, רשות שימוש זו, אף אם ניתנה, הרי שהינה בגדר רשות חנם (הניתנת להפסקה בכל עת) בהעדר כל טענה של הנתבעים, וממילא ללא כל הוכחה, כי ניתנה תמורה כלשהי בהקשר זה לבעלי הדירות האחרים.

שלישית, רק במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושבהם, בהסתמך על מתן הרישיון השקיעו בעלי הרישיון כספים רבים במקרקעין, תוענק לבעלי הרישיון הגנה על הציפייה הלגיטימית שלהם (ר': ע"א 32/77 הנ"ל; ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן פ"ד לא(2) 127; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם בנבו)). בנסיבות דנן לא נטענו כלל, וממילא לא הוכחו, נסיבות מצדיקות כאמור.

לאור האמור הרי ששימוש הנתבעים בחצר הפנימית המגודרת אינו כדין.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני קובע כלהלן:

1. התביעה להריסת תוספת הבניה לדירת הנתבעים נדחית.
2. התביעה להריסת הגדר ההיקפית נדחית. אולם יובהר כי נאסר בזה על הנתבעים, כפי שהמצב קיים כיום, לנעול את השער בגדר האמורה.
3. התביעה לאיטום פתחי הכניסה לדירת הנתבעים מהחצר או לפתיחת פתח לדירתם מחדר המדרגות נדחית.
4. התביעה לסילוק ידם של הנתבעים מחצר הבית המשותף נדחית בכפוף לאמור בסעיף 5 להלן.
5. הנתבעים יסלקו את ידם משטח החצר המשותפת בחזית הדרומית ובכלל האמור יסלקו את הגדר הפנימית התוחמת את שטח החצר הצמוד לדירתם כפי שזו נראית בתמונה בסעיף 8.ה. וכל מיטלטלין המונחים בשטח זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 136/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אין באמור לגרוע מזכות הנתבעים להמשיך ולעשות שימוש סביר ברכוש המשותף ובחצר
אולם ללא גידור השטח ושימוש ייחודי בו.

עתה לפסיקת הוצאות ניהול ההליך.

התובעת בחרה בהליך זה לנקוט בשפה חריפה וחריגה, לרבות במסגרת התנסחותה בכתבי הטענות
מטעמה, הן בהתייחסותה לנתבעים, הן בהתייחסותה לעדים והן בהתייחסותה למפקח, ללא כל
הצדקה ומעבר לכל פרופורציה. די בהקשר זה להפנות לבקשתה בתיק 100/14 (לרבות בתצהיר
הנלווה לה) ולהחלטתי מיום 04.03.14 בבקשה זו. בסופו של יום הוכחו אי דיוקים, בלשון המעטה,
בעדותה של התובעת דווקא.

בהתחשב בתוצאות ההליך (קבלת התביעה בחלקה הקטן בלבד בהתחשב במכלול הסעדים והראיות
בתיק זה), קיומם של 3 דיונים, הגשת תצהירים וסיכומים בכתב והתנהלות הצדדים בתיק זה, לרבות,
בקשות הביניים השונות שהוגשו, אני מוצא לנכון לחייב את התובעת בהוצאות הנתבעים בגין ניהול
ההליך.

התובעת תשלום לנתבעים סך של 10,000 ₪ בגין החזר הוצאות ניהול ההליך בצירוף הפרשי
הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ' אייר תשע"ד, 20 מאי 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב